

1502151-78.2021.8.26.0566

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502151-78.2021.8.26.0566 - 2021/001014

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -
2160717/2021 - DEL.SEC.SÃO CARLOS, 18493924 - DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

PAULO APARECIDO BLASK

Data da Audiência

16/03/2022

Justiça Gratuita

Aos 16 de março de 2022, às 15:30 horas, em virtude da pandemia denominada COVID-19 e das restrições de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos da Resolução CNJ 314/2020, Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e Comunicado CG nº 284/2020, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. DANIEL HENRIQUE SILVA MIRANDA, DD. Promotor de Justiça; do acusado PAULO APARECIDO BLASK, preso na Penitenciária de Araraquara; do Defensor Público DR. LUCAS CORRÊA ABRANTES PINHEIRO; das testemunhas RIVALDO APARECIDO AMBRÓSIO e FELIPE SAKADAUSKAS FERREIRA. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperfis perguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam.

Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas RIVALDO APARECIDO AMBRÓSIO e FELIPE SAKADAUSKAS FERREIRA, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. PAULO APARECIDO BLASK, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, com fixação de pena no mínimo legal e regime inicial fechado. A defesa requereu a improcedência da ação penal. É o relatório. DECIDO. Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou ter praticado os fatos narrados na denúncia. Reporto-me a minha decisão proferida por ocasião da audiência de custódia, que reproduzo adiante: "Conforme consta dos autos, os policiais militares receberam denúncia de pessoa em relação à qual não anotaram os dados pessoais, no sentido de que o indiciado estaria em poder de uma arma de fogo e produtos de furto: '... foram averiguar uma informação dando conta de que Paulo Aparecido Blask estaria mantendo em sua residência uma arma de fogo e produtos de furto; Assim que chegaram foram atendidos, pelo proprietário do imóvel que mora nos fundos, cujo nome ele não anotou, o qual informou que PAULO mora na casa da frente junto com sua mãe ...' (fls. 2). Ao chegarem ao imóvel, narram os policiais que foram autorizados pelo indiciado a ingressar no imóvel o qual foi revistado, sendo que encontraram armas e drogas. Tal situação apresentada como de flagrância não pode subsistir, pois fere o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio. Inicialmente, anoto que não havia suspeita minimamente razoável para o ingresso no domicílio. E como se sabe, nos termos do art. 240, § 1º do CPP, somente se procede à busca domiciliar se estiverem presentes 'fundadas razões que a autorizem'. Evidentemente essas fundadas razões não podem ser encontradas nem são passíveis de controle judicial ex post na notícia não comprovada de que alguém não identificado teria sabido sobre a guarda de objetos proibidos ou produto de crime. Note-se que referido denunciante não foi identificado, sendo que nada nos autos indica que não foi possível sua identificação. Tampouco há registro de que tal denúncia anônima se revestiu de informações sobre a emergência incontornável da suposta situação flagrancial, que autorizasse a ação policial invasiva. Logo, os policiais realizaram abordagem casuística e sem que existisse a fundada suspeita exigida para o ingresso no domicílio do indiciado. A teor do disposto no art. 5º XI da CF/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. A questão do ingresso em domicílio alheio por parte dos agentes de segurança pública ganhou impulso a partir do Tema 280/STF. E novas reflexões surgiram, desde então. (...) Nada mais razoável que seja assim. Qualquer pessoa que seja presa tem o direito a comprovação de que agentes policiais ingressaram no interior de seu imóvel devidamente autorizados pelo morador. Do contrário, a prova será ilícita e a ação do Estado ilegítima. Exceto em situações excepcionabilíssimas - e aquela retratada nos autos não é uma delas, (...) essa comprovação não poderia vir escorada apenas na palavra dos primeiros interessados, qual seja, daqueles mesmos que realizaram a ação, que são justamente os policiais militares. Não por desconfiança. Absolutamente. Mas, sim, porque terão interesse em sempre afirmar que toda a ação sempre se dá no interesse da proteção da sociedade. E como sabemos, sob esse argumento já testemunhamos diversos abusos de toda ordem. Acima da proteção da sociedade, está a preservação da Constituição e das respectivas garantias do cidadão. A se validar o flagrante em tela, criam-se precedentes perigosos, pois a mesma racionalidade poderá ser empregada para todo e qualquer cidadão. Mas, há mais para se argumentar. Ainda que o indiciado houvesse dado o seu consentimento para o ingresso em sua casa - fato que negou veementemente

ao ser interrogado - a formalização desse consentimento era necessária. O contexto fático não dispensa a comprovação formal da autorização para o ingresso no imóvel. Ao se abrir mão de garantia fundamental de tão elevada estirpe (inviolabilidade do domicílio), seria difícil imaginar que a prova dessa dispensa pudesse ser feita através da palavra terceiros, quais fossem, justamente aqueles que ingressaram no domicílio. Note-se que, em casos parelhos (isto é, de dispensa de uma garantia), o registro da dispensa da garantia é formalmente registrado, por exemplo, quando o acusado é advertido pelo juiz de quem tem direito ao silêncio, tudo é registrado. Por qual razão seria diferente em tema de defesa do domicílio? No auto de prisão em flagrante, da mesma forma, todas as garantias constitucionais são expressamente consignadas tal como transmitidas ao indiciado. E bem se vê, assim, que sempre que a ação policial militar permitir, a colheita do assentimento do morador deverá ser feita. E ainda que não o seja no momento da ação, caso seja possível posteriormente, conduzindo-se o morador à repartição policial, também deverá ser formalizada. A jurisprudência dos Tribunais superiores alinha-se exatamente nesse entendimento. Vejamos. "STJ - HABEAS CORPUS Nº 598.051 - SP (2020/0176244-9) EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige. 1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series

(1845) v. 1). 2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva. 2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é

o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação – amiúde irreversível – de todo o processo, em prejuízo da sociedade. 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado. 4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. 5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. 5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos – diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar irritado o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local. 5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial – meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada – legitimar a entrada em residência ou local de abrigo. 6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência – uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio – outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio. 6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (*in dubio libertas*). O consentimento “deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção (*“consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion’*)”. (*United States v McCaleb*, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando

Simmons v Bomar, 349 F.2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (totality of circumstances). 6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito. 6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio (North Carolina v. Butler (1979) 441 U.S. 369, 373; People v. Ramirez (1997) 59 Cal.App.4th 1548, 1558; U.S. v. Castillo (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071, 1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento (Haley v. Ohio (1947) 332 U.S. 596, 601; People v. Andersen (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579). 6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa – ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção –, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, “necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis” (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/TO). 6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal – analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial – ao dispor que, “[f]inda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º”. 7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias – não apenas históricas, mas atuais –, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação – como ocorreu no caso ora em julgamento – de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar.

Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. 8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares. 8.1. As decisões

do Poder Judiciário – mormente dos Tribunais incumbidos de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição – servem para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para “enriquecer o estoque das regras jurídicas” (Melvin Eisenberg. *The nature of the common law*. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna, pluralista e sem preconceitos. 8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA sobre a admissibilidade das provas ilícitas (*Weeks v. United States*, 232 U.S. 383, 1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição, direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não autorizada (“such proceeding would be to affirm by judicial decision a manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action”). 8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança. 9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública. 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e conseqüente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital. 13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal”. Com efeito, nos termos do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no Recurso Extraordinário 603616-RO, inexistia na hipótese justificativa prévia conforme o direito que permitisse a entrada dos policiais no imóvel sem que estivessem amparados por mandado de busca e apreensão. Na ocasião, consignou-se que ‘a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados' (RE 603616, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJE-093 divulg 09-05-2016 public. 10-05-2016). No caso dos autos, não havia situação de flagrante permanente que autorizasse o ingresso da polícia no imóvel. Note-se que as demais situações que autorizam o ingresso em domicílio alheio a qualquer hora do dia ou da noite sem autorização do morador que estão previstas no artigo 5º, inciso XI, da CF/88 são, todas elas, representativas de um contexto emergencial, em que seria absurdo esperar por uma ordem judicial ou pelo consentimento do morador para o ingresso no domicílio alheio: desastre e prestar socorro. A regra é que somente se ingresse em domicílio alheio durante o dia, sem consentimento do morador, com ordem judicial. Essa é a regra, frise-se. Portanto, em princípio, caso a polícia deseje ingressar em domicílio alheio, sem o consentimento do morador, deverá fazê-lo baseada em ordem judicial, mesmo nos casos de flagrante delito. Assim deve ser porque as demais situações que dispensam o consentimento do morador têm sua justificativa no fato de que não comportam razoavelmente que se aguarde por uma ordem judicial. Se existe um desastre ou é necessário prestar socorro, há que se entrar no domicílio alheio. Entretanto, em caso de flagrante delito, não será qualquer hipótese de flagrante permanente que irá autorizar esse ingresso. O artigo 5º, inciso XI, da CF/88 deverá receber interpretação teleológica, justamente por isso. Caso o crime permanente exija imediato ingresso dos policiais com dispensa do consentimento do morador, para se evitar um mal maior, não se deve pensar duas vezes e o ingresso deve ser realizado. Seria o caso de, por exemplo, desaparecimento do corpo de delito, iminência de risco de morte ou lesões corporais, etc. Por outro lado, se o crime permanente, e a respectiva situação de flagrante permanente, não demandam urgência e admitem que se aguarde por uma ordem judicial, esta deve ser buscada em atenção ao devido processo e à garantia da inviolabilidade do domicílio. O presente caso não sugeria, de modo algum, que haveria partida de drogas, tampouco que a prova de eventual traficância seria prejudicada por qualquer demora. Menos ainda que eventuais armas seriam usadas para algum mal iminente ou remoto. A interpretação teleológica constitucional é a que melhor atende aos fins de justiça conforme ensinam a doutrina e a jurisprudência, inclusive em prejuízo das interpretações gramatical, objetiva e subjetiva. Aliás, sob outra ótica, não se pode deixar de notar com surpresa a diferença de proceder costumeiro e vezeiro das atuações militar e civil. Enquanto esta última tem por hábito, procedimento e protocolo solicitar mandados de busca para cumprimento em residências sob suspeita de que nelas seja realizado o tráfico, a polícia militar, ao receber denúncias anônimas, dirige-se ao local informado pela denúncia, invariavelmente diz que recebeu a autorização do morador para ingresso no imóvel e promove a busca domiciliar. Ou seja, enquanto uma polícia (a civil) adota o procedimento constitucional, a outra polícia (a militar), atua de modo inverso". Enfim, entendo que a prova é ilícita por violação de domicílio. Não vislumbro propriamente falta de justa causa para oferecimento de denúncia, uma vez que os elementos de informação em sede de inquérito policial podem ser utilizados para tal finalidade. Ocorre que, reproduziu-se nesta audiência exatamente o que ocorreu no auto de prisão em flagrante, com declarações de mesmo conteúdo, e exatamente por isso a prova é ilícita. Mas não é só. O caso exigia prova pericial sobre o local exato onde teriam sido encontradas drogas e armas, a fim de se verificar o acesso a terceiros estranhos aos imóvel. Mas, há ainda mais. O caso também exigia prévia investigação a fim de se saber

se o acusado efetivamente realizava o tráfico naquela localidade, quem mais habitava o imóvel, quem mais frequentava o imóvel, e enfim, tudo que exige o grau de seriedade de uma prova processual penal com pretensão de imputação de crime de tráfico e de porte de armas. Não houve coleta de elementos de informação sobre abuso policial de natureza física, razão pela qual deixo de determinar instauração

de inquérito policial. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na denúncia absolvendo-se o réu PAULO APARECIDO BLASK da imputação de ter violado o disposto no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e artigo 5º, XI, LVI, da Constituição Federal. Defiro a restituição dos valores e aparelhos de telefonia celular apreendidos ao acusado bem como da pochete, ficando autorizada a destruição dos demais objetos. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA